

1518248-66.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... pela prática de crime de tráfico de drogas perante a 25ª Vara Criminal Central (autos nº 1530681-10.2019.8.26.0228) o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena. Por outro lado não possui outros antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 28/29.

Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518248-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518248-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID WALKER SERAFIM OTAVIANO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

DEIVID WALKER SERAFIM OTAVIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, pois, segundo o apurado, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 16h30min., na Estação de Metrô Santos-Imigrantes, Jardim Colina, nesta Capital, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca "Samsung", "Galaxy M31", pertencente à vítima C.A.R.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia e não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução debates e julgamento, durante a qual foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitiva das testemunhas faltantes.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu com fulcro no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena base no mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com agravante da reincidência; pelo reconhecimento da figura de furto tentado; e, por fim, pela fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante o esforço da combativa Defensora que atua perante este juízo, absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida.

A materialidade do delito veio devidamente comprovada sobretudo pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega do celular ao proprietário, bem como pelo relatório final da autoridade policial.

A autoria também é incontroversa.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática dos fatos descritos na denúncia. Declarou que, na data dos fatos, subtraiu o celular da vítima e saiu correndo. Durante a fuga, dispensou o celular na escada rolante e foi apreendido sem o bem.

A confissão do réu, ao contrário do alegado pela Defesa, foi devidamente corroborada pelo depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório.

De fato, ouvida em audiência, a vítima após fornecer as características do réu e ser colocada a frete de várias pessoas, não teve dúvidas em reconhecer o acusado como sendo a pessoa que furtou seu aparelho celular e ao ser indagada sobre os fatos, narrou que estava no vagão do metrô, próximo à porta, quando o réu passou por ela, e puxou o celular de suas mãos e saiu correndo em direção às escadas rolantes. Por impulso, saiu correndo atrás pedindo ajuda. As pessoas que se encontravam na estação conseguiram segurá-lo e, em seguida, os seguranças da estação chegaram para dar apoio. Informou que os próprios passageiros do metrô recuperaram o celular que havia sido dispensado pelo réu durante a fuga. No mais, disse que não perdeu de vista o acusado durante toda a perseguição, apenas após ele ter sido mobilizado pelos populares. Por fim, declarou que ouviu quando o réu afirmou para os seguranças do metrô que havia dispensado o celular na escada, durante a fuga.

Essas são as provas colhidas sob o crivo do contraditório e diante delas, notadamente em razão da confissão, corroborada pela declaração da vítima, mostra-se suficiente à condenação do acusado aos elementos coligidos durante a instrução.

De outra banda, respeitado posicionamento em contrário e que vem se pacificando em nossos tribunais, para esta magistrada o crime foi tentado já que a vítima afirmou que, ao ter o celular tomado de suas mãos, saiu correndo em direção do réu gritando por ajuda e que, com o auxílio das pessoas que se encontravam na estação do metrô, conseguiu deter o réu e recuperar seu bem, afirmando, ainda, que não perdeu o acusado de vista durante a fuga.

Ora, diante deste relato, para esta julgadora, o crime não se consumou. Adotar sem qualquer reserva a posição jurisprudencial no sentido de que, invertida a posse, consuma-se o crime de furto faria com que o crime de furto tentado quase que desaparecesse e este, salvo melhor juízo, não é a vontade do legislador.

Caracterizada, portanto, a infração penal passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, tendo sido condenado definitivamente pela prática de crime de tráfico de drogas perante a 25ª Vara Criminal Central (autos nº 1530681-10.2019.8.26.0228) o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena. Por outro lado não possui outros antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 28/29.

Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena ser mantida em seu mínimo legal de 01 ano de reclusão; e 10 dias- multa.

Na segunda fase, é o caso de se compensar a agravante da reincidência com a confissão, como, aliás vem decidindo nossas cortes superiores e, portanto, a pena deve ser mantida no patamar acima estabelecido.

Nesse sentido: STJ: "III A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira". (HC 471.436/PE, j. 11/12/2018).

"Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu, ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da confissão espontânea, que, por ser igualmente preponderante, é de ser compensada diante da agravante da reincidência. Apelo parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento". (RJTJERGS 205/176) Na terceira fase incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa na fração de 1/3, tendo em vista que a conduta delitiva apenas não se consumou porque, após perseguição pela vítima, o réu foi capturado por populares quando já se encontrava em outra plataforma do metrô, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 08 meses de reclusão; e 06 dias-multa.

Diante do exposto julgo PROCEDENTE, a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 08 meses de reclusão; e 06 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, já que não há nos autos provas da condição financeira do acusado, por estar incurso no artigo 155, "caput", c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando a reincidência do réu, não é o caso de substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II do Código Penal.

Também não é o caso de aplicação de sursis.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto pois se ajusta e convém a acusado. Trata-se de acusado já condenado por crime de tráfico de drogas e que, após o cumprimento de pena, novamente voltou a delinquir, demonstrando, por ora, que só o cárcere lhe é conveniente.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Não poderá apelar desta em liberdade, pois o acusado já se encontra preso em razão do flagrante e um dos efeitos da sentença condenatória é justamente conservar no cárcere aquele que já se encontra custodiado (art.393, I, do CPP), não sendo recomendável que seja o réu agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva.

Assim, a reincidência do réu e a condenação impõem a necessidade de sua manutenção no cárcere, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois permanecem intactos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Deixo de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo

o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 03/06/2019).

“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o

regime prisional inicial. Precedentes. (...)" .(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 10/04/2019).

Diante disso em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, já com a redação atualizada, dou por revisada e mantida a prisão cautelar do réu.

Como trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorrem de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011)

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA